Justiça Criminal[1]

MARIO SBRICCOLI

A história do "penal"[2] pode ser pensada como a história de uma longa fuga da vingança. *Chave de leitura simplificadora* somente em aparência, se usada como prudente indicação de método, a perspectiva da fuga da vingança (vingança dos indivíduos, das sociedades, dos Estados) é a que melhor revela o tortuoso processo civilizador dos sistemas penais, dando sentido à sua reconstrução histórica e valorizando, de tais sistemas, a função de defesa jurídica das pessoas, dos bens, das sociedades.

Do mesmo modo, a história do processo penal pode ser lida como a longa história do fatigoso advento, cada vez obstaculizada nos fatos, de um aparato de proteção e garantias disposto em torno do acusado e de seus direitos. Esta é uma chave que remete, também, aos níveis de civilização dos ordenamentos punitivos. Enquanto tal, assim como a outra, deve ser utilizada com *sapiência e com uma forte consciência* do risco teleológico que esconde. Porque a justiça penal, tomada como o fim onde direito e processo se consubstanciam, não é historicamente representável no esquema de um constante progresso na direção da civilidade. Ela conheceu crises e regressões, assim como fases onde foi submetida a estratégias *tirânicas* e a *projetos de domínio* político. E pode voltar a conhecer-lhes ainda. Porque reaparecem, tenazmente, também nas sociedades modernas, a vontade de fazer dela um obtuso meio repressivo, ou a pretensão de transformá-la em ocasião de impunidade privilegiada.

1. A justiça penal negociada

Na primeira fase da experiência citadina medieval, entre os séculos XI e XIII, em relação a crimes de algum relevo, a vingança da vítima, ou do seu *entourage*, é um direito. Como tal, ela acaba por absorver uma quota relevante da justiça praticada: não se trata, então, de reprováveis pretensões privadas, nem mesmo de um excesso tolerado, mas, ao contrário, de um modo reconhecido para restabelecer equilíbrios violados, para conseguir um ressarcimento e obter satisfação. Um meio ordinário de justiça, então, que possui evidentes origens germânicas, se radicou nas mentalidades e no costume, e que repousa sobre a convicção de que os crimes que atingem as pessoas – na vida, na incolumidade, nos bens, na honra – são assuntos privados, a serem tratados entre os interessados, envolvendo famílias e amigos, se necessá-

rio, mas não os poderes públicos. Ou, ao menos, não necessariamente.

Motor e finalidade da vingança é a satisfação, coeficiente estratégico do penal nas suas origens. Mas a satisfação – complexo conjunto de elementos morais e materiais – parece estar, paradoxalmente, nas origens da própria crise tardo-medieval da vingança, como prática ordinária de justiça. Diferentemente da *faida*, que, ritualizando e circunscrevendo o uso da violência, cumpre uma de suas funções de longa duração no governo das hostilidades persistentes, a vingança não é uma prática privada de inconvenientes para a vida associada (induz a desordens, faz pouco caso das normas, elude poderes, desvaloriza autoridades): os poderes públicos a combaterão com dissuasões e proibições, orientando os cidadãos a modos de obtenção da satisfação diferentes daquele simplificado e arriscado, que se resolve no fazer ao outro aquilo que ele fez a ti. Mediadores e pacificadores são mobilizados para que a laceração induzida por um delito venha sanada com reintegrações e ressarcimentos, com trocas, indenizações e recompensas. A negociação, porém, não exclui absolutamente o recurso ao juiz: porque, se é verdade que somente a punição do culpado não basta para a satisfação do ofendido, é verdade também que da abertura de um processo público ele poderá tirar uma certa força de negociação, a investir na negociação "privada", que é aquela que conta. Uma vez alcançado o acordo, o processo poderá sempre ser interrompido.

A ideia de que o delito é, em primeiro lugar, uma ofensa (*injuria*) que importa antes reparar do que punir, que a reparação consiste na satisfação e que a satisfação deve passar por uma negociação, está solidamente instalada na cultura daquelas primeiras comunidades citadinas e condiciona de maneira *constitutiva* a sua concepção de justiça. Uma concepção que funda a justiça sobre o *pertencimento* e sobre a *proteção*, "reservando-a" aos membros da comunidade, sujeitos reconhecíveis, e, enquanto tais, garantidos. Os cidadãos, fossem eles os últimos por condição e classe, gozam de uma forma de tutela ou "salvaguarda" que faz da justiça (negociada) comunitária um assunto de coassociados e que opera, por assim, dizer, *embaixo*. Ela exclui os forasteiros, os vagabundos, os *sans aveu*, e todos aqueles que, mesmo membros da comunidade, foram separados dela por terem sido colocados contra ela (bandidos, *latrones*, incendiários, delinquentes habituais, *inner foes*, mas também *disturbers* tidos como incorrigíveis ou desviantes considerados perigosos): esses são *intractabiles*, e por isso submetidos a procedimentos públicos sumários, frequentemente expeditos, finalizados com a pena e ditados por um espírito de eliminação. É outra ideia de justiça: aquela que combate o crime *do alto*, usando aparatos e buscando obediência, aquela que assegura a vingança pública e pune para retribuir, mas também para dissuadir, com a inexorabilidade e exemplaridade da pena; que não está na lógica da reparação tratada em relação à ofensa, mas na da repressão unilateral da violação e da remoção do perigo.

A justiça negociada repousa sobre o *consenso*, antes e mais do que sobre a *certeza*. Somente lá onde a aprovação da comunidade é presumida, se dá preeminência à certeza: é assim para as ações criminais de quem não tem proteção ou é tido como incorrigível, e é assim para os crimes sem vítima, que compreendem muitos *crimina enormia* como a heresia, a apostasia, o sacrilégio, a lesa-majestade nas suas numerosas manifestações ou as práticas sexuais consensuais reunidas sob o *nomen generale* de *crimen sodomiticum*. Aqui a resposta repressiva se declara inexorável, não admite negociação, não dá subterfúgio, nem

concede garantia. Digo "se declara" porque os documentos que encontramos nos arquivos nos mostram que, na presença de protagonistas de estatura adequada, as soluções negociadas encontram, frequentemente, uma janela por onde voltar: em particular naquilo que diz respeito à efetiva execução das penas, ainda assim irrogadas.

Pertencimento, proteção, consenso e, acrescento, *oralidade,* remetem ao caráter *comunitário* da justiça negociada. E aquela parcela de negociação ou consensual que a justiça penal conservará em seguida repousará constantemente sobre o princípio da comunidade, deixando em poder das jurisdições locais os conflitos entre vizinhos que assumem a forma penal.

Mas as transformações constitucionais não deixam de se refletir no caráter do penal, determinando-lhe modificações. A observação dos pactos constitucionais das formações políticas tem fundamental importância no estudo do penal, porque ele tende a conformar-se naturalmente às lógicas constitucionais dos poderes que o exprimem. *E então, é indubitável que entre os* séculos XII e XV uma transformação radical investiu o sistema citadino italiano, levando-o de uma fase "comunitária", gerida com regras consuetudinárias, a uma "autoritária", dominada por partidos e assembleias, que vai desaguar nos regimes senhoriais e depois em Estados territoriais estruturados, atentos a garantir para si formas eficazes de jurisdição. Novas formas de governo se impõem, mudando totalmente a relação entre senhores e súditos, entre direito e poder. Tudo isso induz progressivamente a ajustes no regime punitivo, que inicia justamente a partir do enfraquecimento da autonomia da função de justiça e do questionamento do seu caráter negociado.

A vingança, praticada nas origens como um *direito,* entrará em conflito com a lógica constitucional da Comuna madura, mas salvará o seu núcleo distintivo (a satisfação) conferindo-lhe à negociação e enraizando, por assim dizer, o seu *espírito* na essência profunda do penal histórico; do mesmo modo, a justiça negociada se tornará cada vez mais incompatível com as ordens constitucionais dos regimes centralistas nascidos da crise das cidades. Ela *preservará o seu núcleo distintivo* escondendo-o nas *práticas* que presidiam o novo modo de fazer justiça, enquanto o seu espírito continuará a condicionar os sistemas penais, até o fim dos antigos regimes.

2. A justiça hegemônica de aparato[3]

Um novo modo de fazer justiça. Entre *o fim do século XIII e os inícios do século* XIV imprime-se ao penal um forte caráter de publicização. Os governos citadinos se dão conta de que a justiça penal é um decisivo meio de governo e que não há sentido deixá-la somente à iniciativa das vítimas. Os juízes dos *podestà* começam a agir de ofício na persecução de todos os delitos de qualquer relevância. Fazem *inquisições gerais, indagam em vastos raios* para descobrir se foram cometidos crimes; encorajam as acusações para que os delitos não fiquem impunes; abrem processos depois de denúncias e os levam a cabo, condenando o culpado, mesmo quando a vítima, satisfeita negocialmente, se "repacificou" com ele e não tem mais nenhum interesse no processo. *Incidem, portanto, de modo decisivo* sobre a práxis de transação e acomodação, desacreditando o seu fundamento consuetudinário, enquanto alguns juristas[4], sensíveis às renovadas lógicas constitucionais, inauguram uma crítica "cultural", que opõe à desordem da autonomia comunitária uma ordem nova feita de normas, de interesse geral, de paz pública e de justiça distributiva.

Impõe-se o princípio no qual quem comete um delito lesa a sua vítima, mas ofende também a *respublica*, a qual tem o direito de obter satisfação infligindo uma pena.[5] E para levar a cabo tal princípio, ao juiz outorgam-se afiados instrumentos bastante penetrantes: vigorosos meios de interrogatório (incluindo o uso da tortura) e poderes "arbitrários" (isto é, conferidos com a concessão de um *arbitrium*, entendido como um poder vasto mas regulado) no que tange às acusações a mover, ao modo de proceder, à coleta das provas e à pena aplicável. A partir desses elementos nasce um processo, que, por comodidade, chamamos *inquisitório*, destinado a conotar a própria ideia de justiça por um longuíssimo tempo, que chega praticamente até nós.

O novo modo de fazer justiça assume rapidamente traços hegemônicos. Reduz enormemente os espaços da negociação em matéria penal, impondo como princípio a oficiosidade da ação pública, a indisponibilidade do processo e a sua direção conferida ao juiz; enfraquece o papel da mediação social na solução dos conflitos nascidos de crimes, porque impõe a ideia de que não há justiça sem a *punição* do culpado. Enfim, promove um modelo processual (que recolhe as provas através de *inquisitio*) que marginaliza progressivamente o tipo processual acusatório (lugar ideal da mediação e da justiça negociada, aberta à querela, gerida pelas partes, decidida por um juiz terceiro que não tem poderes de investigação), reduzindo-o à negociação de crimes menores, a conflitos locais, às justiças baixas e periféricas.

A hegemonia que a justiça penal "autoritária" consegue sobre a justiça "consuetudinária e estipulativa" se favorece (mas poder-se-ia dizer que deriva desta) das transformações que investiram as ordens constitucionais dos Estados da primeira Idade Moderna. Dirigida em primeiro lugar à *repressão*, ela é fundada sobre a *submissão*, regulada por *normas legislativas* e *doutrinais*, administrada por *aparatos* cada vez mais articulados e difusos, progressivamente *formalizadas* num âmbito onde domina a escritura.

A justiça que indico como hegemônica[6] se orienta sobre quatro pressupostos técnicos: a lei, a ação, a prova, a pena. Os juristas compõem estes pressupostos nas *practicae*, realizando um intrincado mas engenhoso *sistema*, útil para os juízes e produtor, ao mesmo tempo, de um direito penal novo. Por último, os *aparatos*, produzidos pelos Estados para administrar pessoas, recursos, relações, e, portanto, *justiça*, serão, juntos, o contexto forte da justiça hegemônica e um vetor dessa hegemonia.

2.1 *A lei*

Bem se compreende como a lei (designo com este termo equívoco as normas postas por uma autoridade) constitua o fundamento primário para uma justiça que, cuidando menos do consenso, privilegia a certeza. Ela tem o caráter de evidência, garante firmeza e possui o vigor necessário para conseguir a obediência. A dicção da lei não é passível de negociação: pode ser ignorada, elidida ou evitada, mas representa um elemento de qualquer forma antagônico à lógica do negociado.

Há que se falar que, por um longo tempo, a "legislação" restará esparsa e setorial: até o fim do século XV, oscilará entre raras constituições imperiais e decretais pontifícias, estatutos, ordenações, provisões, capitólios, bandos, destinados a cobrir pequenas áreas do direito penal substancial e zonas apenas um pouco mais gerais do processual. No mais, também lá onde será organicamente e intencionalmente produzida, não se imporá tão facilmente nos termos nos quais nós pensamos uma lei

e o seu vigor. Permanecerá subordinada à "justiça", atributo do poder do príncipe, e se imiscuirá nas práticas dos tribunais, primeiro desfiada e depois "digerida" dentro da lógica anti-imperativista do direito comum. No panorama normativo emerge, então, o trabalho da doutrina. Os juristas filtram, interpretando-a e organizando-a em sistema, as normas produzidas pelas autoridades políticas, e, no entanto, aproveitando muito do direito romano, produzem outras, muito mais numerosas, extensas e orgânicas, que se voltam aos juízes, com o efeito de disciplinar e orientar a prática da justiça. O seu prestígio assegura a esta operação completamente cultural (mas com extraordinários efeitos políticos) sucesso e duração, enquanto a sua adesão às lógicas constitucionais e políticas dos ordenamentos nos quais operam garante aos governantes coerência de entendimentos e organicidade nos projetos.

2.2 *A ação e a prova*

São os dois pilares do processo público de caráter inquisitivo, substância da justiça de tipo hegemônico. Já alertei que os tipos processuais ditos "acusatórios" e "inquisitórios" correspondem substancialmente a duas maneiras diferentes de recolher a prova. As suas estruturas distintas, os meios diferentes de que são dotados, o poder que têm de determinar, cada um a seu modo, a própria natureza da justiça praticada repousam sobre o diferente método empregado para alcançar a prova. Do mesmo modo, a ação (privada e discricionária, ou pública e obrigatória) orienta para diferentes formas processuais a que se podem dar início. A justiça de tipo hegemônico se vale de um processo prevalentemente por ação pública (com o tempo cada vez mais invasivo), em que a coleta da prova é confiada ao poder de investigação do juiz e é baseada num amplo leque de meios intrusivos e coercitivos, contra os quais parece frágil querer opor a precária disponibilidade dos débeis meios de defesa à disposição do acusado.

2.3 *A pena*

A justiça hegemônica se afirma graças a um aparato penal e processual orientado principalmente à irrogação da pena.

Norma, ação, processo padronizado, coleta de provas convergem para um mesmo ponto: colocar o juiz em condições de punir aqueles que provocaram um dano com dolo. A pena assume, nesse quadro, uma centralidade especial: é *signum imperi seu potestatis*, dispositivo de justiça, meio de exemplo e dissuasão, objeto e ocasião de *arbitrium*, expediente retributivo, mas também lugar e ocasião para o resgate da dimensão "negociada" do juízo, fundada sobre o costume, sobre a equidade, sobre a misericórdia. O seu temperamento tem viva a imagem do *bonus iudex* e introduz na justiça praticada elementos sofisticados de valoração penal: a responsabilidade penal, a culpabilidade, o elemento psicológico, as circunstâncias encontram o seu lugar na elaboração de uma doutrina da dosimetria da pena, que tem larga parte na elaboração das *practicae*.

2.4 *Os aparatos*

A justiça assim construída e praticada desenvolve uma inevitável função de "modelo" e gradualmente invade estilos e modos da justiça negociada tradicional, que, com o tempo, ganha as cores, características e formas da justiça hegemônica, até ser de fato absorvida na sua tipologia. A própria ideia de justiça sofre uma torsão relevante (do distributivo ao retributivo, do consenso à imposição, da negociação possível à repressão inevitável), porque a natureza dos poderes hegemônicos implica um deslocamento de todos os pontos de referên-

cia da periferia para o centro, do baixo ao alto, do vínculo horizontal à sujeição vertical, da práxis relacional como contexto do juízo ao aparato como matriz dele.

A justiça entendida como modo de resolver conflitos (também de caráter penal) com práticas compartilhadas, dentro de lógicas comunitárias e sobre o princípio da *compensação, mostra abertamente o seu* lugar secundário com respeito às exigências dos novos sistemas de poder. Em termos *lato sensu* constitucionais, a verticalização dos processos de poder em que pouco a pouco investem os Estados da Idade Moderna, e a produção normativa que se liga a esta, tornam-se fontes necessárias de um sistema judiciário modelado sobre os traços do penal hegemônico.

Segue-se, assim, a gradual instauração, nos Estados nacionais e em alguns dos antigos Estados italianos, de uma justiça fundada sobre *ordenações* (o advento da profissionalização, um início de burocratização e a ideia de controlar o território junto com os juízes), hierarquizada, com centros dominantes e periferias delegadas, confiada a tribunais supremos que exercitam funções de apelo e difundindo os argumentos de suas decisões, promovem a integração das políticas judiciárias, a uniformidade dos estilos e a progressiva homologação das práticas consuetudinárias locais.

Vale a pena repetir que, apesar de tudo, somente uma pequena parte da cultura da composição morrerá para sempre, nem secarão de uma só vez as raízes da vingança. Ainda em pleno século XVI florescem as negociações de paz, as tréguas e as concórdias, a criminalidade baixa continua quase inteiramente apanágio de procedimentos fundados na *accusatio*, a composição extrajudicial mantém o seu espaço. A atitude de negociação e a ideia de represália serão banidas do campo penal somente com a chegada das codificações, depois da grande virada histórica da Revolução Francesa: mas também o absolutismo dos códigos deverá prestar contas com a longa duração e adaptar o seu passo àquele, muito mais lento, da cultura dos povos e das pessoas.

Pequena, eu dizia, no curso dos antigos *regimes, a parte de cultura da composição* que se perderá. O grosso permanecerá, ainda que enfraquecido por uma progressiva marginalização, e flanqueará a justiça hegemônica de aparato mantendo um grau quantitativo de todo respeito. E não só. Entre os dois níveis parece realizar-se uma verdadeira osmose de estilos de conduta, no sentido de que se a cultura da negociação *sofre a hegemonia da justiça de aparato* e a essa imperceptivelmente se conforma, essa última termina por adotar mais de uma das características da primeira. Em particular, a propensão à acomodação parece abandonar a fase de abertura do processo e do seu desenvolvimento, para refugiar-se no momento de execução penal. São a sentença emanada e a pena estabelecida que reabrem a *bargaining*, segundo uma lógica que é perfeitamente símile àquela que inspirava a justiça negociada *d'antan*: voltam à cena novamente os níveis de integração e proteção, o *intuitus personae*, a mediação dos poderosos, o papel da comunidade, a influência da Igreja, os recursos utilizáveis e, por que não, o arbítrio de quem tem o poder de decidir[7].

3. As *"practicae criminales"* e a autonomia do direito penal

As *practicae criminales* são o pilar doutrinal da justiça de aparato e a razão "não última" da sua hegemonia.[8] Asseverativa e prescritiva ao mesmo tempo, procedem sobre um duplo registro: legitimar com a *consuetudo practicandi* o procedimento tal como ele é, e ditar ao juiz o que ele deve

decidir – sobre punir ou não, sobre como e quanto – defronte à infinita casuística que se pode apresentar: crime por crime, hipótese por hipótese, circunstância por circunstância, sem deixar variantes, teorias alheias, argumentos contrários a evitar, precauções a tomar e limites, sobretudo limites, a não transpassar. Com as *practicae* o processo é governado, e delas pouco a pouco se desenvolverá, partindo da realidade dos fatos, um direito penal atualizado, tecnicamente mais rigoroso e, sobretudo, autônomo.

A realidade dos fatos. Ippolito Marsili ovaciona a *practica*, "rerum magistra", fonte da *vera interpretatio*, porque o uso prático, junto com a experiência, torna expedito e frutífero o trabalho de quem tem o encargo de administrar os interesses públicos dos diversos príncipes e lugares. "Parum prodest habere theoricam ipsarum causarum criminalium sine practica"[9]. O jurista se socorre, então, fundindo ciência e experiência numa obra única, destinada aos *artifices iustitiae*, aqueles que "fazem concretamente" a justiça. Práxis processuais e percursos judiciários (*formae inquisitionis*) compõem uma espécie de tessitura sobre a qual se dispõe uma trama de figuras delituosas, imbricada com uma espessa rede de casos, tipos e circunstâncias; de definições, princípios jurídicos, máximas e opiniões comuns, *quaestiones et dubia*; de tipologias indiciárias, modos e graus de prova, técnicas de exclusão, modelos e fórmulas de procedimento de interrogatório e sentença. Tudo com o escopo principal de mensurar sobre cada figura particular o *an*, o *quomodo* e o *quantum* da pena a aplicar.

O próprio pilar do processo é o efeito prático de ações sucessivas que partem da *notitia criminis* e aproam na sentença. A *Practica* prescreve ao juiz de certificar-se, antes de ir adiante, que o delito tenha realmente acontecido, e depois de prosseguir com as vistorias, coleta de indícios materiais, busca por testemunhas, interrogatórios. Depois, uma vez identificado o suspeito, seguirão a *inculpatio*, a procura por provas ou indícios a encargo do juiz, a tentativa de obter uma confissão (inclusive através de tortura, se necessária e possível), ou de qualquer forma a *convictio*,[10] para depois encerrar com uma sentença correlata os resultados do processo. Há que se acrescentar que as *practicae* não se ocupam da execução da pena, campo deixado à esfera administrativa e completamente tomado pela negociação.

O jurista *theoricus-practicus*, graças ao juiz que o aplica, produz então um direito que tem sua origem na prática e que perpetua aquela prática convertendo-a em *ius*. O juiz que se deixa guiar segue as suas indicações e as estabiliza numa *consuetudo iudicandi* que se torna logo *norma agendi*. Daqui, a *Practica* sucessiva não fará mais referência a certas operações como àquilo que acontece *de facto, quamvis contra ius*, mas àquilo que *de iure fieri debet*.

O penal que se depreende das *practicae* constitui, então, a base de abertura para práxis posteriores, que realizarão ulteriores deslocamentos e ajustes, que, por sua vez, serão corrigidos e incluídos no sistema de outras *practicae*. É assim que os juristas governam a formação e a gestão do penal, afinados com os aparatos, expressão direta das exigências políticas dos órgãos citadinos e dos Estados. A finalidade política da justiça se entrelaça com as teorizações dos juristas, que na persecução desse fim conferem racionalidade, base técnica, credibilidade e consenso, além do necessário lastro de legitimidade. A intervenção do jurista tem, então, ao menos duas valências. Por um lado, racionaliza, governa, corrige, motiva e coloca conforme os princípios jurídicos as práticas de justiça dos aparatos, com isso desenvolvendo uma função de

consolidação, que é, ao mesmo tempo, operação de controle e ocasionalmente de moderação; por outro lado, vem construindo do interior das *practicae*, segundo a lógica que indiquei e que procurarei esclarecer posteriormente, um direito penal substancial que mostre a *regula recti* a um poder de punir naturalmente inclinado ao abuso. Um direito que se apresente imediatamente como critério de referência, para depois se constituir como conjunto de princípios gerais que sejam moderadores da lei por um lado, disciplina da justiça administrada por outro. Timão, rédea e freio, diriam aqueles juristas, assim como hoje poderíamos dizer garantia.

As *practicae*, enquanto "iudicibus maleficiorum, advocatis vel causadicis, cancellaris et aliis versantibus in palatio, tironibus ac veteranis, perutiles ac necessariae"[11], são sim orientadas ao processo (seria melhor dizer "pensada para os juízes"), mas incubam princípios e dogmática no campo do direito penal substancial muito mais do que no que tange ao processo. Porque do ponto de vista estritamente processual as *practicae* são, na realidade, – e paradoxalmente – pobres. Partem do pressuposto de que o juiz "tem poderes", ou melhor, deveres, e legam a esta única precondição a construção das *figura iudicii*. De resto, pouco cuidando dos direitos do acusado, aqueles juristas não podiam fazer outra coisa senão construir uma doutrina processual "reduzida", quase inteiramente absorta na questão dos *limiti* ("iudex debet, potest, an debeat, na possit, non debet, nequit"[12]). As *practicae* de maior fôlego (a de Giulio Claro, por exemplo, ou a poderosa *Praxis e theorica* de Prospero Farinaccio[13]) enfrentam em termos doutrinais – além das questões comuns a todos, *accusatio, denunciatio, inquisitio* ou as regras da tortura –, também alguns nós de natureza estritamente processual (competência, recusa, *exceptiones*, nulidade), mas o empenho na identificação do *mussen* e do *sollen* se sobrepõe a qualquer aprofundamento teórico.

Diferente é o discurso quanto ao direito substancial, porque grande parte dos *posse* e dos *necesse* encontram raramente a sua razão em alguma regra processual (é o caso da doutrina da prova), mas em um princípio de direito penal. O juiz se encontra conduzido pela mão em matéria de responsabilidade penal, culpa, imputabilidade e causas de justificação, de dolo e de culpa, de tentativa, concurso de pessoas, circunstâncias, reincidência, dosimetria da pena, além de tudo o que concerne à individuação das condutas que integram cada crime e as suas difíceis definições. Nessa obra, que ainda continua a construir-se a partir da prática, a cognição dos princípios penais se afina,[14] as noções vêm submetidas a uma crescente racionalização, e um princípio de sistematicidade começa a mostrar-se na reflexão de alguns penalistas mais conscientes da necessidade de dar *autonomia* ao direito penal, fazendo da norma substancial um *prius* em relação à verificação processual da sua violação.[15]

É, de fato, na inversão da relação entre norma e processo o ponto nodal que constitui a fragilidade das *practicae* e do sistema de justiça que elas nutrem, expondo-o às infiltrações da negociação e tornando difícil a emersão de um processo penal, por sua vez, autônomo e, nessa medida, mais bem garantido. É o ponto que vai determinar, entre os séculos XVI e XVII, a degeneração do hegemônico gerido pelos juízes e centrado no processo como máquina de produzir justiça, manifestação, entre outras, do poder absoluto do príncipe.

Na nossa perspectiva de modernos, o processo penal é subordinado às normas do direito penal material. Não se dá processo sem violação, e não se dá violação se antes não estão bem estabelecidos os princípios,

os âmbitos, as condições e os limites daquilo que (pela lei) é previsto como punível. Isso porque as normas substanciais, se observadas, exaurem em si todo o sistema penal: nenhuma violação, nenhuma justiça "a fazer". É a lógica de uma concepção imperativista de direito. Mas não é assim no aparato hegemônico do Antigo Regime, para quem a justiça, se assim posso dizer, "preexiste", e emana do Poder (concepção absolutista), não diversamente daquilo que sucederá à lei na experiência dos Estados liberais de direito. A maneira "pragmática" com a qual aquela justiça é aplicada implica (e induz) uma concepção *sui generis* das normas substanciais: não prioritária, não pressuposta, mas endereçadas ao juiz como referência para juízos interpretativos sobre os atos dos justiciáveis, dos quais importa principalmente valorar a *pravitas*, a nocividade, e o grau de *desobediência* que exprimem.

4. O paradigma da infração política e a expansão do penal entre os séculos XVI e XVII

Uma nova concepção do penal, iniciada há muito tempo, mas que amadureceu lentamente, se impõe na Itália e em grande parte da Europa ao longo de todo o arco do século XVI. As suas consequências sobre as ideologias penais se projetarão numa longa duração que atravessará, inclusive, o divisor de águas da Revolução Francesa.

Tal concepção repousa sobre o deslocamento da relevância penal de um ato ou de um comportamento do plano do *dano* ao da *desobediência*, que corresponde à extensão do esquema da infração política a toda violação penal de qualquer relevo. A base dessa concepção é o vínculo sempre cada vez mais estreito que ancora a justiça à lei, que cresce na opinião geral, até fazer-se ideologia e senso comum, segundo a qual qualquer violação de uma obrigação penal pode ser assimilada a uma perigosa forma de indisciplina.

Quando digo que nesta passagem se lê a forma paradigmática do crime político, pretendo referir-me a dois aspectos.

a) O primeiro, teórico e de fundo, está na assunção de toda transgressão penal ao esquema da "ofensa à *res publica*", segundo o antigo raciocínio que servira a Alberto da Gandino para legitimar a ação de ofício do juiz "de quolibet maleficio": o poder público pune porque não pode consentir que se ofenda-o, ainda que o dano atinja em concreto qualquer outro. Consolida-se o princípio do *parere legibus et praeceptis superiorum*[16], que passa de preceito moral à obrigação jurídica penalmente sancionada, e se enraíza progressivamente um *severo desfavor pela infração*. A simples desobediência à lei penal se torna motivo de punição: algo que parece absolutamente óbvio aos nossos olhos, mas que não era uma novidade pequena, e custou a afirmar-se, no contexto daquelas sociedades habituadas a uma relação diferente com a dimensão normativa e a um outro modo de fazer justiça.

b) O segundo, por assim dizer histórico, repousa sobre o fato de que todos os crimes comuns de qualquer relevância são tratados num processo penal que foi pensado e construído, *olim*, para a persecução da heterodoxia religiosa e da oposição política radical. Esta característica originária teve consequências enormes sobre a configuração dos sistemas penais da Idade Moderna: não somente no que tange à justiça praticada, mas também na fisionomia impressa aos traços normativos do direito pe-

nal substancial. Aquele era o processo pensado para o inimigo. Em termos jurídicos, vêm dali os enormes poderes inquisitivos do juiz e os precários direitos de defesa dos imputados, o exercício conjunto da função investigativa e judicante, o segredo das acusações e do inquérito, a possibilidade de negar a defesa aos acusados (sobre os quais incumbe, contudo, a obrigação de dizer a verdade), a possibilidade de usar a tortura e excluir a apelação.

Nada surpreendente, então, se o emprego secular daquela lógica processual, combinada com o advento de uma legislação bastante severa (e evasiva em relação aos costumes penais estranhos ao "paradigma da infração política"), fará amadurecer a convicção, primeiro combatida, depois, enfim, dominante, que "fazer justiça" consiste em reprimir, que a tarefa dos aparatos judiciários é "combater o crime", que os criminosos são inimigos e que os Estados, tendo pretendido o monopólio da justiça penal, têm o dever de "representar" súditos e sociedade no exercício de uma *eficaz* vingança contra aqueles.

É óbvio que o direito penal substancial não se furta a essa lógica. Tomemos o penal alto, aquele monopolizado pelos aparatos, que avocou à sua justiça e submeteu às suas práticas a quase totalidade dos conflitos de formato penal: o que vemos é um sistema no qual a identificação entre justiça e repressão produz um verdadeiro *fall out* de efeitos secundários de indubitável relevo. Indico três deles:

a) A transfusão dos princípos doutrinários elaborados nas *practicae* em grandes *Leis gerais* emanadas por príncipes, que *enrijecem* seriamente o sistema de incriminação e do juízo. Os dois principais exemplos são a *Constitutio Criminalis Carolina*, promulgada por Carlos V em 1532 para os territórios do Império, e a *Ordonnance Criminelle* emanada para a França em 1670 por Luís XIV. Destinada a modificar e tornar confiáveis as políticas penais através de uma rigorosa ressistematização do processo, procurarão impor um novo estilo de conduta aos aparelhos de justiça. Ao mesmo tempo em que lembram o sistema das *practicae* (primariedade do processo e "processualidade" do direito penal substancial), por outro lado reduzem muito a flexibilidade desse sistema, diminuindo, assim, a negociabilidade, subtraindo mais um *arbitrium* do juiz e, sobretudo, excluindo o recurso aos costumes normativos ou processuais, graças às quais sobreviviam negociações e justiças comunitárias. Explicam-se, assim, as furiosas resistências das populações e das comunidades locais ao advento da *Carolina* e, na área francesa, a difusa elusão à *Ordonnance Criminelle* e, bem antes dela, às *Ordonnances* di Tours (1493) e Blois (1498) além da de Villers-Côtteret de 1539. As grandes leis vêm em procura de certeza e eficácia e, portanto, impõem um processo inquisitório muito penetrante, produzem (e reforçam) aparatos, obtêm um relevante efeito de admoestação e terrificação, reduzem ao mínimo a relevância das justiças comunitárias e das jurisdições locais, dão ao hegemônico uma extraordinária aceleração e mostram com toda a clareza que a *iurisdictio in poenalibus* é inteiramente do príncipe.

b) O sistema penal se orienta à *prevenção geral*. O complexo das criminalizações se alarga, tende a assumir tons pedagógico-moralistas que mal distinguem o pecado do crime e concorre, assim, para um geral processo de *disciplinamento* da sociedade. Aos mesmos

fins contribui o agravamento do sistema sancionatório introduzido pelas grandes leis e o persistente uso que se faz do processo como expediente para esmagar os crimes mais graves, ou mais temidos, através de procedimentos expeditos, *ad modum belli* – como se faz na guerra, se dizia –, que asseguravam em primeiro lugar, e de qualquer modo, a punição dos culpados. Entre os séculos XVI e XVII assiste-se, então, a um crescimento da pressão do penal sobre a sociedade e a um surpreendente incremento da criminalização primária[17]. Manifestam-se emergências inesperadas que fazem a repressão penal recair sobre a divergência religiosa e o desvio moral, e a perseguir de maneira organizada sujeitos e comportamentos *borderline*, postos num esquema de criminalização completamente *sui generis*, especialmente se vistos pelo referencial daquela (não irracional, não inconsciente) ciência jurídica. Refiro-me à perseguição da bruxaria, *crimen maleficii, sortilegii vel magiae*, conduzida, em surpreendente penúria de dúvidas, com um refinamento extenuado de racionalidade probatória (a ponto de chegar à prova certa de fatos inexistentes), e com um inimaginável abuso da tortura e da confissão. Tanto que a história, que dizem ser astuta, seria refeita, dali há não muito tempo: o nexo de causalidade entre ação e evento faria o seu ingresso na valoração da responsabilidade penal, a tortura judiciária teria logo um descrédito mortal, a confissão perderia, em relação às outras provas, a sua coroa de rainha.

c) Emergem, em termos que podemos chamar de "modernos", as exigências da ordem pública. O deslocamento de foco do dano à desobediência, que contamina a resposta penal com a marca da infração política, limpa o caminho para a lógica da *prevenção*, com o seu cortejo de suspeitos e prejulgamentos. A "pequena legislação" (éditos, bandos, ordens, notificações, regulamentos) torna-se pletórica, invasiva, "disciplinante". Entre os séculos XVII e XVIII começa a ganhar forma um *outro* nível penal, gerido *ad arbitrium* pelas polícias, inspirado no critério da *periculosidade*, baseado igualmente sobre prejulgamentos e sobre informações, nada estranho, nos estilos adotados, a alguns aspectos do modelo da Inquisição romana, sobre o qual vou acenar dentro em pouco. Destinado a crescer enormemente como "penal do cotidiano dos pobres", dará vida a um segundo nível de legalidade, subtraído da jurisdição e por isso provisto de uma especial autonomia: será um dos hóspedes inapresentáveis que sentarão à mesa dos futuros Estados liberais de direito.

5. A justiça ordinária e o modelo da Inquisição romana

Uma atenção há de ser dada ao modelo processual adotado pela Inquisição romana, e, sobretudo, aos *modos* (organização, condutas, astúcias) que caracterizaram a sua ação.

O processo praticado pela Inquisição romana não é diferente do seu contemporâneo processo ordinário, comumente utilizado para os grandes criminosos nos Estados italianos (e não somente neles). Mesmas fontes originárias, mesmas regras, mesma doutrina de base como referência. O rito da Inquisição e o *iudicium publicum* ordinário têm em comum as suas longínquas origens normativas[18], usam as mesmas regras fundamentais,[19] fazem-se governar pela mesma doutrina, que sirva de prova o fato de que os manuais inquisitoriais, que dirigem a ação de inquisidores e juízes

eclesiásticos, são construídos com as recorrentes fontes de direito comum: juristas civilistas e canonistas, direito romano e canônico, as escrituras, alguns teólogos, exatamente como as *practicae criminalis* que os juízes ordinários tinham sobre a mesa. O processo inquisitorial é estruturado do mesmo modo que o processo penal público: a mesma ação (movida por acusação, denúncia, fama ou *notitia criminis*), as mesmas regras da *inquisitio* (geral e especial), as mesmas práxis e cautelas para os interrogatórios, as mesmas regras para a tortura, os mesmos critérios para a valoração das provas e dos indícios, a mesma relação entre o processo informativo e a repetição dos testemunhos,[20] o mesmo *arbitrium* concedido ao juiz na irrogação da pena: de onde vem a amplíssima gama de sanções figurativas, simbólicas ou alusivas, medicinais, penitenciais ou autenticamente penais que os juízes da Inquisição aplicam caso a caso.

O sistema processual da Inquisição mostra, todavia, traços peculiares, nas formalidades, no estilo de conduta, na organização do aparato. Alguns desses traços se apresentam como especificações de inclinações que o processo hegemônico público da sua parte também conhece. Penso na *centralização e hierarquização da atividade judiciária*, que, porém, a Inquisição realiza em *escala italiana*, produzindo uma "unificação" judiciária que ignora os confins das jurisdições estatais, avoca competências dessas jurisdições e as recompõe, prescrevendo aos inquisidores periféricos critérios uniformes e exercitando um controle bem organizado, muito atento e eficiente, sobre as suas atividades. Penso na forte *legalização da ação dos juízes*, vinculados a textos normativos certos e direcionados não a partir de interpretações próprias, mas de um intenso e contínuo afinamento das regras, as quais provê a Congregação do Santo Ofício sobre a base da experiência e da casuística que chega a Roma de toda a Itália: o juiz que tem dúvidas deve dirigir-se aos superiores, com questões escritas, definidas, circunstanciadas. Penso, por último, numa certa atenção ao *profissionalismo* do pessoal judiciário, que transparece nas instâncias da Congregação.

Mas a Inquisição se caracteriza também por peculiares inflexões de estilo, e por práticas *sui generis*, que são somente suas. Por exemplo, a mobilização de *sinergias externas* ao aparato de justiça, a começar pelos órgãos públicos de cada Estado, chamados frequentemente a colaborar, para terminar na espessa rede de religiosos seculares e regulares difusos do modo que conhecemos em todo o país; além disso, uma estável *linearidade de conduta* que a justiça pública não possui, porque a justiça pública continua estruturada no pressuposto de que deve articular-se e adaptar-se aos casos, às situações, às circunstâncias, mesmo quando se trata de justiça penal. Não que a Inquisição, eventualmente, não faça o mesmo, mas ela parece fazê-lo no interior de um estatuto de conduta que surte efeitos lineares mesmo na eventual variedade de soluções adotadas. Para além das aparências, creio que se possa dizer que a Inquisição não negocia e não é laxista: as suas "concórdias" e as suas indulgências são ritualizadas, direcionadas aos seus escopos, não extemporâneas.

A Inquisição é muito atenta ao *rigor das formas* e tem, ao mesmo tempo, as cautelas que garantem resultados, e as cautelas que mostram prudência com o acusado. Neste espírito era dada grande importância ao respeito pelos procedimentos, às verbalizações (que sejam integrais e escrupulosas), à conservação dos documentos, à formação de uma acurada rede de arquivos. No procedimento informativo se assegura o segredo dos movimentos do juiz, dos motivos e das intenções, para incrementar

a eficiência, e se assegura o segredo dos atos, também num espírito de garantia. Há atenção pela defesa dos acusados no processo repetitivo (ingresso dos defensores, acesso aos atos), prudência sobre a qualidade e proveniência das acusações, declarada hostilidade contra os anônimos, desconfiança em relação aos testemunhos não juramentados, cautela no encarceramento, providências para a defesa dos pobres.

O sistema processual colocado em marcha pela Inquisição romana se apresenta, então, como um tipo evoluído do penal hegemônico. Um autêntico modelo exemplar, provisto de notável força atrativa sobre os ordenamentos dos Estados italianos, que muito assumirão do seu estilo, projetando esse modelo numa longa duração.

5.1 O precedente da "Carolina"

A Inquisição, enquanto exemplo maduro da justiça de aparato, se encontrou, então, construindo "a justiça da lei", enquanto o hegemônico atravessava ainda, na Itália e na Espanha, a fase evolutiva das práticas. Fê-lo adotando as mesmas inderrogabilidades, as mesmas cautelas e garantias, os mesmos expedientes e estratégias de uma lei famosa sobre a qual já acenei, a *Constitutio Criminalis Carolina,* colocada em vigor por Carlos V em 1532, dez anos antes que Paulo III, com a bula *Licet ab initio,* abrisse caminho à Santa Inquisição. Que haja um nexo material de derivação entre o *stylus* adotado pela Inquisição romana e a *Carolina* é algo, que eu saiba, não demonstrado. O que me parece claro é que ambos os *sistemas* estão no rastro do hegemônico maduro, e que aquilo que no modelo da Inquisição é *estilo* de conduta, maneiras, estratégias, na *Carolina* é norma de lei.

Algumas das homologias, constituindo paralelos e inovações em relação às práticas consolidadas, atingem-nas de modo particular. Assinalo algumas delas: a lei de Carlos V vige sobre quase todo o Império germânico, se vale de um aparato judiciário estruturado a partir do centro, difuso sobre o território, com escritórios uniformizados e com juízes especializados, nomeados e aprovados pelas autoridades centrais. O processo que constrói se apoia sobre um texto normativo certo e tem, portanto, uma vigência geral, *erga omnes,* mas aquilo que conta mais, é *cogente para o juiz,* que deve se submeter à lei. Se o juiz tiver dúvidas quanto à norma da *Carolina,* consultará as autoridades superiores. As suas demandas serão escritas, documentadas e circunstanciadas minuciosamente. Deve jurar que não fará diferença entre pobres e ricos, fracos ou fortes, que não agirá por amor ou por ódio, que não desejará recompensas e não aceitará presentes. Não será capcioso no interrogatório, não colocará ninguém sob tormentos fora dos ritos, terá sempre a lei diante dos olhos.

Não diversamente de como os manuais fazem com o inquisidor, normas detalhadas guiam o juiz nos interrogatórios de acusados e testemunhas, bem como na coleta e valoração dos indícios e das provas. L'*ars inveniendi ac ponderandi indicia*[21] da justiça penal ordinária está em simetria com a *ars interrogandi* da Inquisição, porque é homóloga ao nexo *intentio-factum* (ou melhor *conscientia-actus*). O inquisidor é, em primeiro lugar, o juiz das *intentiones* e da *conscientia*, enquanto o seu homólogo ordinário vai, sobretudo, à procura de ações e fatos. O primeiro tem como meio ordinário a *extorsio verborum*, o segundo a *collectio indiciorum*.

A lei se preocupa com a confiabilidade do processo. Normas precisas são postas como garantia contra os iníquos, os pretensiosos ou acusações imprudentes; a lei assegura uma (muito circunscrita) defesa aos acusados e dispõe a transmissão (com encargos)

do processo informativo aos defensores, com a indicação das testemunhas e das suas declarações; outras normas regulam o uso da tortura, a tutela das testemunhas, a adoção de *cautelae de veritate*. Na chamada de cúmplices (instrumento soberano para descobrir e caçar bruxas), Inquisição e lei Carolina vão *pari passu*: todas as cautelas adotadas pelos inquisidores, frequentemente louvadas como sinal de uma superior atenção às garantias, à confiabilidade das acusações, à transparência das investigações, são já inteiramente asseguradas pelo art. 31 da *Carolina*. Enfim, uma minuciosa disciplina prescreve verbalizações (interrogatórios, defesas, confissões) e registros (provas, indícios, alegações), disciplina a transmissão e conservação dos atos, obriga ao segredo e dá vida ao arquivo.

As analogias. Elas sugerem a ideia de um processo da Inquisição que está a pleno título dentro de um estágio processual "ordinário", que emprega os mesmos materiais de que é feita a justiça penal dos Estados e está numa relação de sustento e nutrição *recíproca* com a cultura judiciária do hegemônico. Um detalhe não pouco importante está no fato de que a Inquisição perseguia opiniões e processava inteligências, sufocando aquelas sociedades num tornilho de suspeitos e temores que a duras penas deixava respirar; a sua "justiça" não ressarcia vítimas, nem retribuía a quem houvesse materialmente lesado, com dano e com dolo. Defendendo o bem da ortodoxia, destruía o bem da liberdade. E o fazia *na raiz*, agredindo pensamentos e palavras, para meter-se entre as unhas da consciência. Isso, quanto ao mérito, como dizem os juristas. Quanto ao método, pode-se dizer que a sua tradição, feita de sagacidade investigativa, de lúcida correção, de frio equilíbrio entre regras a observar e resultados a alcançar, famosa pela seriedade e pelo estilo, que são a outra face de uma legenda negra feita de prudentes impiedades e pérfidas astúcias, que servirão para alimentar e afiar o processo penal inquisitório dos Estados continentais, adentrando ainda no século XX!

6. A degeneração das práticas, os intelectuais reformadores e as primeiras codificações penais[22]

No curso do século XVIII, duas tendências, com uma longa sinergia histórica às costas, atracam nos seus (diferentes) epílogos, realizando as condições de uma transformação radical no campo da justiça penal. De um lado, a concepção de direito e de justiça criminal que indiquei sob o nome hegemônico realiza completamente a sua progressiva prevalência e, no final do século, se apodera de maneira definitiva de todo o campo penal. De outro, a justiça das práticas, durante séculos laboratório e vetor do hegemônico em ascendência, resolve a sua crônica decadência numa intolerável degeneração, entra em mortal contradição com a constituição ideológica da idade nova, aparecendo de súbito arcaica e bárbara.

6.1 Pela primeira vez na história da Europa, os intelectuais...

O direito penal racional e a justiça civilizada que a idade nova pretende tomam forma nas críticas corrosivas que um grupo de ideólogos reformadores, difusos e conectados em escala europeia dirige com grande agudez e eficácia contra os ordenamentos existentes. Pela primeira vez na história da Europa os intelectuais desenvolvem uma função crítica de oposição, em coro e conflitiva, e o fazem no campo penal, atribuindo-lhe uma centralidade cultural e política que não perderá mais[23]. De Montesquieu a Voltaire, de Rousseau a Beccaria (que depois de 1764, ano de publicação do *Dei delitti e delle pene*, foi eleito o relutante corifeu do reformismo penal iluminista), com Blackstone e Bentham na Inglaterra, Verri, Filangieri e Pagano na Itália, Sonnenfels na Áustria, Hommel na Alemanha, Lardizabal na Espanha, um coro de intelectuais que

primeiro impôs a discussão e depois a reforma do sistema penal europeu.

É o triunfo do hegemônico, conjugado à razão. Em primeiro lugar se invoca a lei. Uma lei ditada por um legislador que represente a vontade de toda a sociedade, que se preocupe da sua defesa, que individualize com certeza delitos e penas, seguindo o princípio da utilidade social, único critério de justiça. O juiz, servo primeiro da lei, se limitará a aplicá-la.

Direito e processo são regenerados num quadro de princípios que emergem de uma virada histórica: o referente ético-religioso, que dominava o penal há séculos, é redimensionado para dar lugar à prevalência dos direitos, laicidade e razão, utilidade e proporção, ordem, certeza e garantia.

Transplantados para o âmbito substancial, estes conceitos inspirarão o princípio da legalidade dos delitos e das penas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), a unicidade do sujeito de direito na ordem penal, o respeito às liberdades pessoais, e, portanto, a irrelevância penal das escolhas de consciência, das manifestações de pensamento, das condutas privadas socialmente irrelevantes. Abre-se a partir daqui o longo caminho da "despecatização", ou secularização, do direito penal substancial: a incriminação partirá somente da lei, e as figuras delitivas serão somente aquelas estabelecidas pela lei. O princípio de legalidade traz consigo o da irretroatividade da lei penal e a proibição de aplicá-la de maneira analógica. As normas serão abstratas e gerais, conformes aos princípios fundamentais da convivência civil, úteis ao bem social, não caprichosas e não persecutórias. A responsabilidade penal será pessoal, e pessoal será a pena, que deverá ser pública, imediata, certa, proporcional ao delito, inelutável se devida, aflitiva mas que não perverta o réu, dissuasiva para os outros, emenda para o culpado. Assim se resumem as três principais diretrizes da ideologia do Iluminismo penal (humanitarismo, utilitarismo, proporcionalismo), aos quais se acrescenta a atitude abolicionista: a pena de morte é banida, junto com as penas corporais, infamantes e as que revertiam seus efeitos sobre inocentes (o confisco, a *damnatio memoriae*).

Nenhuma negociação, e, todavia, nenhum unilateralismo irracional repressivo: a justiça deve saber ser clemente, as penas são suavizadas e praticadas principalmente com multa e cárcere. O espírito de civilidade será o princípio inspirador das normas e da sua aplicação. As normas de direito substancial são separadas, conceitual e materialmente, daquelas que regem o processo, e disciplinam juntas as prerrogativas do Estado (que detém o poder de punir) e os direitos dos acusados.

6.2 *Processo e poderes do juiz*

A reflexão sobre a justiça praticada nos processos parte da figura e do poder dos juízes. Entre os séculos XVII e XVIII, a crise progressiva da justiça prática tinha, em geral, o rosto dos juízes: traídos pelos governos se incontrolados, parciais se submetidos ao poder político, nem sempre tecnicamente capazes, às vezes corrompidos, considerados responsáveis pela justiça trágica que havia caçado os *untori*,[24] as bruxas, os hereges, os inocentes, eram a personificação da justiça arbitrária. Aos reformadores, que muito discutiram sobre os poderes do juiz e sobre a alternativa entre um sistema probatório legal (provas predeterminadas, que vinculam o juízo) e o seu livre convencimento, parecera, enfim, que a melhor via fosse a de submeter rigorosamente os juízes à lei, negando-lhes até mesmo poderes interpretativos e relegando-os à limitada função de apuração dos fatos. A lógica dos juízos conduziria a êxi-

tos variáveis, mas a ideologia antimagistratural manifestou-se com muita força, tanto nesse como em campos próximos.

O processo era recolocado num eixo totalmente diverso daquele que norteava o sistema das práticas. Nada de acusações secretas, nem fases reservadas ou escondidas dos acusados. A investigação probatória torna-se transparente, saindo da lógica indiciária e demolindo o confuso sistema de provas legal, rígido, arcaico, pouco confiável. O ônus da prova competirá somente a quem acusa e os acusados, aos quais será assegurado como inviolável o direito de defesa, não serão submetidos a juramento, tampouco constrangidos fisicamente à confissão: ao contrário, começa a delinear-se na cena do processo o direito ao silêncio do acusado, que entre as suas prerrogativas tem certamente a de não se expor. Passo decisivo para o início de uma viagem longuíssima, ainda inconclusa, que modificará a natureza e o sentido do processo penal, transformando-o de máquina de obtenção de provas (antes de tudo) contra o imputado, num lugar funcionalmente orientado a garantir-lhe o exercício da defesa. Nessa mesma direção estão a necessidade de bem definir a competência dos juízes (por lugar, por matéria), pressuposto para a garantia do juiz natural, a exigência que as sentenças sejam motivadas e sujeitas ao apelo, e a oportunidade de submeter a controle de direito também os provimentos interlocutórios dos juízes. E que as decisões sejam colegiadas, envolvendo mais magistrados, e abrindo caminho ao juízo popular através do instituto do júri.

6.3 Leis feitas de passado que abrem o futuro

Robusto elemento de reforma, junto às históricas abolições da tortura e da pena de morte, é possível encontrar na *Leopoldina* a lei toscana de 1786, pela vontade de Pietro Leopoldo inovadora, mas ainda exposta, pela sua estrutura "à antiga", à intrusão dos métodos das práticas. É, portanto, no *Codice generale sui delitti e sulle pene* de 1787 e no *Ordine giudiziario criminale* de 1788, pela vontade do imperador Giuseppe II, em que identificamos o primeiro exemplo de codificação penal moderna, largamente inspirada nas ideias dos reformadores. Encontram-se ali acolhidos o princípio da legalidade, a proibição da analogia e de heterointegração, generalidade e abstração das normas, uma moderna "parte geral", uma divisão racional das matérias, proporção das penas, restrição da pena de morte somente ao caso de sedição perigosa para a existência do Estado, abolição da tortura. Estes, e outros numerosos exemplos, fazem do código giuseppino um protótipo que, até o século XIX, será imitado de várias formas; dele, uma última opção deve ser sublinhada: a imprescritibilidade da pena, estabelecida pelo § 183 do livro I, signo, acima de qualquer outro, de uma justiça estatal que não negocia, exatamente no ponto que representava o último reduto da justiça negociada em retirada.

A Revolução Francesa, filha dos princípios elaborados pelos intelectuais reformadores, se tornará a mãe destes princípios, recolhendo, concretizando em normas e difundindo as novas doutrinas penais e os fundamentos do novo processo. Já a partir da *Déclaration des droits de l'homme e du citoyen* de agosto de 1789 – na qual se afirmam as liberdades do cidadão defronte a uma justiça penal subtraída do domínio absolutista –, e depois, com a relevante produção legislativa da Assembleia Constituinte, toma forma um sistema penal radicalmente novo, revisto no processo, na organização judiciária e no próprio método de repressão. A Constituinte, com numerosos provimentos, entre os quais se destaca a adoção de um Código Penal em setembro

de 1791, introduz uma classificação tripartida das infrações (crimes, delitos, contravenções), de acordo com as penas, que fará escola; adota o princípio da articulação das matérias objeto de proteção, segundo uma ordem afirmada nas doutrinas dos *philosophes*,[25] que passará com esparsas variantes à generalidade dos códigos que seguirão, até hoje; conservará a pena de morte, mas recorrerá pela primeira vez de forma preponderante à pena de prisão; colocará uma forte ênfase na defesa das instituições públicas e do Estado e uma grande atenção aos crimes contra a propriedade: todos os elementos que caracterizarão plenamente a codificação penal do sucessivo século XIX, e não somente esta.

6.4 Os blocos de granito de Napoleão Bonaparte

Ao novo César que governava a Europa, as posições dos constituintes e o código de 1791, deviam lembrar demais as ideias de Beccaria. O *Code d'instruction criminelle* de 1808, regredindo em relação ao *Code des délits et des peines* do ano IV (1795), cria um processo misto, dominado pelo caráter inquisitório na fase instrutória, estruturado com os métodos do Antigo Regime (ausência do imputado, penetrantes poderes do juiz, recolha unilateral das provas); o debate, porém, se funda na oralidade, publicidade, contraditório e espaço para a defesa: mas o processo chega ali, na maioria das vezes, já prejudicado pelas mãos do juiz instrutor.

Em 1810 Napoleão ab-roga o código de 1791 e coloca em vigor o seu *Code pénal*, verdadeiro bloco de granito na história da codificação penal. Este código nasce marcado pelo projeto político cesarista que o inspirava em larga medida: defender a ordem social e pública, proteger o Estado e o governo, dissuadir e intimidar, ameaçar e desencorajar. Penas muito severas (incluindo o banimento, degradação civil, berlinda, marcas a fogo, decepamento da mão e bolas de ferro nos pés: "Despojos dos séculos mais bárbaros", teria dito Beccaria), morte e confisco cominados abundantemente; reaparecem as penas perpétuas, se nega o princípio da proporcionalidade em matéria de tentativa e cumplicidade, aumenta exponencialmente a pena dos reincidentes, revivem-se os critérios de incriminação do crime político que se imaginavam extintos com a queda do sistema do *crimen lesae maiestatis*. O arbítrio da lei, dir-se-ia, toma o lugar do arbítrio do juiz. Tudo isso não evita que o código de 1810 fosse claro, bem articulado, ordenado. Ao juiz, depois da experiência das penas fixas com o código de 1791, vem restituído um certo poder de adaptar a sanção, dentro dos limites fixados pela norma; delineia-se a ideia de circunstâncias atenuantes, ainda que depois seja reduzido ao osso o rol das descriminantes; os direitos do cidadão são menos tutelados que no de 1791, mas o código não os esquece.

As razões da grandeza, da fortuna e da tenacidade deste código estão provavelmente na sua consonância com a íntima e oculta *constituição* do século XIX continental europeu: ele exprime de fato a mais coerente (e dinâmica) tutela sancionatória pensável do modelo (napoleônico) de direito privado, individualista e autoritário, dos quais estão embebidos os Estados de forma liberal, antiliberalmente governados. Mas estão também na modulação da sua estrutura, que se prestava a reacomodações progressivas, de acordo com os tempos. Uma lei de 1832, fruto da revolução liberal de 1830, aboliu a marca e a berlinda, atenuou as penas, trouxe o remédio das circunstâncias atenuantes, dizimou o batalhão de crimes capitais, concedeu maior peso ao júri. O código renovado que dali nasce toma o aspecto de um *code pénal progressif*, acrescenta ao velho

prestígio a nova aurora liberal e conhece uma segunda fase imitativa: ecoa no Piemonte (1839), com consequências sobre a futura legislação da Itália unida, no Vaud (1844), na Espanha (1850), na Prússia (1851), em Portugal (1852), e se irradiou pelos Estados alemães, que sofreram o influxo do *Strafrechtsgesetzbuch für die preussischen Staaten*, obra de qualidade notável, como de resto sucede também, depois da unificação alemã, ao código para o império alemão de 1872.

7. Juristas, justiça, política e lei no século XIX. A penalística civil

Adotados em toda a Europa, os novos códigos sancionam o ingresso da justiça no domínio exclusivo da lei. Revolução nada pequena, que coloca em primeiro plano a relação entre direito e política e produz um efeito sob vários aspectos inesperado: a *centralidade da questão penal*. Tema político feito de matéria técnica, ela retorna à responsabilidade dos juristas, depois do longo período no qual foi avocado, por assim dizer, por ideólogos e *philosophes*.

A. A centralidade da questão penal

É uma centralidade feita de problemas concretos e de dinâmicas que investem o sistema. Problema concreto, por exemplo, é a emergência criminal, que investe os campos e depois recai sobre as cidades e que a difusão da imprensa cotidiana entre as classes proprietárias torna objeto politicamente sensível e "perigoso" para os governantes. Problemas concretos são a eficiência da justiça, a sua "natural" orientação classista, o recrutamento e a função dos juízes, os poderes e o comportamento das polícias, o estado das prisões. Mas a questão penal se encontra no centro de dinâmicas de outra natureza, e certamente não menos relevantes. Pode-se dizer que ao longo de todo o século não haveria problema aberto, em matéria de crescimento civil, de liberdade, justiça ou evolução política, que não atravessasse em algum ponto o sistema penal. Adquirir ou garantir a menor das liberdades comportava a reescritura ou abolição de uma norma penal, de uma proibição, de um crime. Cada novo elemento de civilidade que viesse a enriquecer a sociedade através dos seus ordenamentos trazia consigo transformações, muitas vezes importantes, da ordem penal vigente.

Os juristas são então investidos de uma responsabilidade muito grande. Os dilemas que eles mesmos construíram, e que atravessam todo o século desenhando um eloquente diagrama de fases alternadas, são aqueles que repousam sobre o conflito entre ordem e liberdade. Quais dos dois interesses deveriam prevalecer quando parecessem inconciliáveis? E pode um Estado comprimir (ou suspender) as liberdades dos cidadãos para conservar a si mesmo, assumindo a própria conservação como condição para a existência dessas liberdades? Um *bem político* – a segurança do Estado, a ordem da sociedade – vem oposto ao *direito que tem cada um* de usufruir da sua liberdade. O conflito se representa na eterna dialética de prevenção e repressão, no duplo nível de legalidade (a legalidade assegurada pela jurisdição e aquela administrada pelas polícias), na difícil convivência entre as razões da justiça e os direitos dos culpáveis. A contradição entre ordem e liberdade, contudo, é posta sob o pano de fundo do embate de classes que caracteriza o século XIX, porque é esse embate que lhe dá sentido e a torna perigosa. E pode-se estar seguro de que, cada vez que se sentir ameaçada, a classe governante optará pela ordem, ainda que o sistema tanto se orgulhe de proclamar que se funda na liberdade.

B. Criminalidade e justiça nos Estados pré-unitários

Na Itália, nos Estados pré-unitários, entre 1815 e 1860, a justiça é fortemente con-

dicionada pela defesa de regimes políticos débeis, impopulares, amedrontados. Os aparatos tratam de limitar as liberdades dos súditos, para impedir que exprimam, difundam ou organizem divergência política. Garantidores dessa ordem são as polícias, provistas de regras próprias, que escapam à garantia da legalidade, e é bastante raro que os opositores, a não ser que se exprimam com atentados ou revoltas violentas, sejam encaminhados aos aparatos da jurisdição. Por razões de eficiência operativa, dir-se-ia, mas também porque é árduo ter como "justiça" a repressão de ações que não fazem vítimas, não são violentas, e partem de motivos idealistas e são direcionados contra regimes sem popularidade, com prognoses de vida nada longa.

Também no plano da justiça ordinária estes Estados sofrem para comprar algum consenso que não fosse muito custoso. Os seus códigos são inspirados por concepções autoritárias, construídas sob a chave da dissuasão, com níveis de penalidade elevadíssimos, intimidatórios antes que repressivos. Por outro lado, há com frequência uma criminalidade rural da sociedade de penúria, nas quais se movem faixas marginais que, não sendo mais capazes de assegurar a subsistência dentro dos antigos circuitos de sustento comunitário, se tornam transgressivas pela necessidade. O impacto com a justiça destas populações, nas novas condições normativas, é fonte de resistências e divergências, se não fosse pela perda brusca do *privilégio de impunidade* que as práxis concediam, em certas condições, a alguns dos mais difusos ilegalismos. O novo processo, como também o âmbito das garantias já inelutáveis (e, todavia, enfraquecidas: defesa excluída da instrução e de fato limitada aos abastados, apelo circunscrito a particulares condenações, prisão preventiva *sine die*, permanência de procedimentos especiais agravados para certos crimes), vem de regra orientado, se não prejudicado, pela defesa da investigação reservada às polícias e se apresenta de qualquer forma hostil e custosa, sobretudo em relação às causas menores, que continuam as mais difusas e que outrora poderiam resolver-se "paternalmente" com juízes contíguos e não funcionarizados. Mas o domínio da lei e o processo de estatalização do direito e da justiça eram já incontrastáveis. Tratava-se, e seria missão doutrinária, de constitucionalizá-lo e de ancorá-lo a princípios liberais, para torná-lo fator de crescimento e civilidade.

C. Emergência e legalidade

O reino da Itália nasce, em 1861, sob o signo da emergência. A insurreição de homens armados em algumas das regiões meridionais, que ficou na história com o nome apressado de *brigantaggio*, pareceu colocar em grave perigo a unidade do Estado há pouco realizada. A reação do governo foi tal, no plano normativo e da prática de justiça, a infligir, *status nascendi*, ao sistema penal italiano uma radical e irreversível torsão. A legislação de exceção contra o "brigantaggio" e os métodos utilizados para aplicá-la imprimiram ao ordenamento punitivo uma espécie de caráter originário, que o acompanharia, de emergência em emergência, até os anos 80 do século XX. A Itália se adaptou a esse duplo nível de legalidade, já praticado pelos antiliberais Estados pré-unitários, que os artífices do Risorgimento, então no governo do Reino, sofreram e combateram, e o conservou, fazendo-o operar e arrastando-o muito além do limite assinalado em 1948 pela Constituição republicana; assim como adotou o método da legislação especial de emergência constelando a sua história de lei de exceção que, uma após a outra, deixaram no ordenamento rachaduras e detritos.

D. A penalística civil da Itália liberal

Os juristas, ao menos alguns, se colocaram contra essa corrente. O primeiro foi

Francesco Carrara, mestre reconhecido dos penalistas italianos da segunda metade do século, que criticou a fundo a intrusão da "razão de Estado" na lógica penal e da justiça. Outros o seguiram, numa crítica cerrada dos defeitos do sistema punitivo, atenta aos aspectos técnicos, preocupada com os efeitos políticos de certas escolhas, consciente da centralidade do penal, que concebia em estreita correlação o respiro liberal do ordenamento com a civilidade do país. Uma geração de penalistas liberais (que uma indolente tradição historiográfica arrolou numa inexistente "escola", zombeteiramente chamada de "clássica" pelos adversários),[26] cientificamente realistas e capazes de empenho civil, realizou depois de um árduo trabalho de 30 anos um código penal de grande qualidade. Inspiraram-no homens como Francesco Carrara, Enrico Pessina, Emilio Brusa, Giovan Battista Impallomeni; fizeram-no principalmente Luigi Lucchini, colaborador do ministro Zanardelli, que lhe deu o seu nome. Código liberal, com penas equilibradas, moderadas pelo critério da bipartição dos crimes, numa escala penal civilizada pela abolição da pena de morte, com uma boa visão das questões então nodais (tutela dos bens constitucionais primários, princípio da estrita legalidade, imputabilidade bem definida, ressistematização "garantista" da tentativa e da relação entre dolo, culpa e responsabilidade objetiva, tipificação rigorosa, disciplina da reincidência).

Mas o código Zanardelli se apoiava num código de processo envelhecido e de inspiração absolutamente diversa, aplicado por uma polícia orientada em outras direções e se valia de um sistema carcerário inapresentável. Em torno a estes nós se debruçou exaustivamente a penalística civil da segunda metade do século: duas gerações de juristas das mais diversas orientações, liberais, realistas, positivistas, democratas e socialistas, divididos por vivas discussões, mas confluentes na mesma função de progresso científico e de vigilância política. Juristas que deram a mais alta prova de si, em particular, na crise do final do século, que foi uma dramática crise de legalidade em primeiro lugar. Entre 1894 e 1900 reapareceram leis de exceção e estados de assédio, instrumentos de um projeto autoritário voltado a conter a imperiosa demanda por "cidadania" (e dignidade) que vinha do mundo do trabalho; a este projeto se opuseram, junto com outros, vários expoentes da penalística civil italiana: professores, juízes, advogados, de proveniência diversa, juntos num empenho no qual investiram ânimo e inteligência para afirmar a irrenunciabilidade de um sistema penal justo, de garantias, e livre. Foi uma batalha civil difícil, arriscada e custosa, mas foi combatida com dignidade e firmeza, abertamente e sem espírito de economia. As revistas científicas, a imprensa cotidiana, os tribunais, o Parlamento e por fim as praças foram o teatro de um embate no qual o papel daqueles penalistas foi decisivo e exemplar.

8. Fascismo e Estado Forte. A longa fase do penal autoritário

A questão penal, depois de ter figurado no centro de um grande debate na Europa do século XIX, conhece na primeira parte do século XX uma fase de recomposição e estabilização. Na Itália, a doutrina, alavancada por Arturo Rocco, coloca o direito penal no passo do quadro constitucional real do país, assumindo a *lei* como pilar fundamental da reflexão do jurista. É a virada tecnicista, benéfica por um lado, porque contribui para sanear a ciência penal, liberando-a dos detritos da invasão positivista (terríveis sociologismos, autoritarismo áspero, repressivismo antiliberal), mas também precursor de um empobrecimento cultural que, a longo prazo, os penalistas pagarão com um penoso isolamento.

Recomposição e estabilização, dizia. É verdade que permanecem não resolvidos os crônicos nós de uma justiça lenta, custosa e classista, de uma polícia que não tem o cuidado devido com os direitos dos cidadãos, de um sistema carcerário atrasado demais; todavia, do ponto de vista dos princípios e dos métodos, o direito penal construído e depois afinado pela penalística civil do século XIX é suficientemente adequado a uma sociedade somente em parte tocada pela modernidade, como a italiana da primeira metade do século XX. Como o são também os códigos, o de Zanardelli e o novo código de processo penal de 1913, liberais até onde bastasse, moderados até onde servisse. Mas a traumática tomada de poder da direita-fascista faz irromper exatamente no campo penal o embate político, sinalizando os novos perfis vexatórios da repressão.

8.1 A cultura penal do fascismo e as suas leis

Desde o primeiro momento da sua tomada de poder, o fascismo italiano tende a colocar no centro do problema penal o embate político. Dos anos do "squadrismo" até à solução de força da crise Matteotti, aportam nas reformas "fundantes" de 1926, toma forma *in nuce* uma espécie de projeto penal que o regime metabolizará, para restituí-lo em formas ideológicas e em realizações legislativas inspiradas num projeto não destituído de coerência. Alguns fundamentos parecem evidentes. Em primeiro lugar, o penal vem desancorado da tradição liberal, para ser reduzido à arma que o Estado apontará para os seus inimigos, em defesa não da sociedade e dos cidadãos, mas de si mesmo, com isso assegurando a tutela daquela e destes. Não será mais questão de direitos ou de garantias, mas de autoridade. O Estado para ser forte deve fazer-se temido, e, para este fim, instrumentalizará a repressão penal, definindo *ad libitum* os âmbitos de liberdade dos cidadãos e a "compatibilidade" das suas ações. Corolário deste princípio é a assunção do criminoso como inimigo, numa gradação que prevê a aniquilação dos opositores políticos, inimigos por excelência, a severa punição dos criminosos comuns, o assujeitamento dos perigosos ou "anormais" ao mais estrito tratamento preventivo.

A legislação penal do regime oscila entre as leis "fascistíssimas" de 1926 e as anti-hebraicas de 1938. No meio, em 1930, uma imponente reforma de todo o sistema ligada aos dois códigos, penal e de processo, por Alfredo Rocco. As leis de 1926 aniquilam a oposição política, suprimem os partidos políticos e a liberdade de imprensa, retomam a pena de morte para os crimes políticos, instituem o Tribunal especial para a defesa do Estado. Os códigos de 1930 se inspiram numa visão meramente defensiva, alçam o nível da repressão tornando consideravelmente mais áspero o sistema de penas, apostando na intimidação. Títulos inteiros traduzem em normas penais alguns fundamentos da ideologia política do fascismo: o Estado-pessoa e a sacralidade da nação, a natureza totalitária do partido fascista identificado com o Estado, a intolerância pelas oposições, a ideia fascista de família, a religião do Estado, a economia corporativa, a obsessão pela pureza da estirpe, e até mesmo o costume machista do fascismo, vinham protegidos como bens primários da sociedade e da nação em diversos, e às vezes estratégicos, títulos introduzidos no código.

O processo penal, que então se colocava no esquema misto típico da tradição italiana, é construído de maneira tal a tornar decisivos os resultados da inquisição instrutória, destinada a ser revertida no debate, com o efeito de orientá-lo de maneira praticamente irreversível. As provas são recolhidas no curso da instrução: a preliminar, confiada à polícia, a sumária, desenvolvida pelo Ministério Público, e a formal,

que toca ao juiz instrutor: em nenhuma das três é admitida a presença do defensor do acusado. Como sucedia no processo das práticas, os resultados da instrução lhe serão dados no ato ou na véspera do reenvio ao juízo. Pouco se preocupa o código da liberdade pessoal dos imputados: para os crimes de qualquer relevo a prisão preventiva é a regra e, em não sendo previsto termo, sucede que o imputado passa na prisão todo o período do processo, inclusive na apelação, independentemente do seu êxito final. Inútil acrescentar que o Ministério Público depende hierarquicamente do ministro da Justiça e que sobre as suas decisões de arquivamento não é dado controle jurisdicional: é como dizer que a ação penal está discricionariamente nas mãos do Ministério Público, o qual, por sua vez, por assim dizer, está nas mãos do ministro.

Nada pequena, em tudo isso, como escrevi em outro lugar, fora a responsabilidade dos juristas. Imersos sem resíduos numa cultura autoritária que lhes tinha apagado qualquer preocupação pelos direitos, deixaram circular na sociedade, originado do aparato penal, um espírito de domínio que se exercitava sobre as pessoas e sobre as formações sociais, nas relações políticas e na vida cotidiana. Um espírito não separável da prática do arbítrio e do abuso, que tomava forma corriqueiramente nas relações entre autoridade e cidadão. Aquilo que um sistema penal liberal deveria combater e esconjurar, esse sistema encorajava e praticava. Entraram no horizonte da normalidade a inclinação fascista à vexação dos adversários, o impulso de anular o *disturber*, o desprezo pelo *inferior* por condição social, raça ou conduta. Porque o paradigma da superioridade/inferioridade, o princípio da desigualdade, o preconceito da hierarquia social, a intolerância pela diversidade e os múltiplos corolários da doutrina da força, uma vez absorvidas na lei e colocadas em marcha concretamente como "critério de justiça", vinham, depois, restituídas à sociedade sob a forma de ideologia e visão das coisas. De tudo isso os juristas, cada vez que esqueciam a função humanitária e liberadora que ao penal fora assinalada pela penalística civil do século XIX, traziam uma dose de responsabilidade nada pequena.

9. Democracia e Estado Social. A crise do penal na Itália republicana

Depois da Liberação, a conquista democrática restituiu ao sistema penal o seu caráter de medida do grau de civilidade do sistema jurídico e de toda a sociedade. Graças a poucas passagens da Constituição de 1948, obtiveram solene sanção o princípio da legalidade e a do juiz natural, a personalidade da responsabilidade penal, a presunção de não culpabilidade, o direito à defesa, a função reeducativa da pena e a abolição da pena de morte. Os códigos do fascismo continuaram, porém, em vigor, apenas moderados por *desuetude* e, a partir de 1956, por numerosas intervenções demolidoras da Corte constitucional; os seus pesos, todavia, se fizeram sentir, junto ao da lei de segurança pública, agindo como estridentes freios sobre a vida civil e democrática do país.

A partir dos anos 1950, o sistema penal italiano, envelhecido e urgindo por reformas, em grave atraso em relação ao desenvolvimento civil e econômico de um país já em vias de rápida modernização, vem investido por uma série sucessiva de *emergências* que ditaram, por assim dizer, a sua agenda: a *ordem pública*, em relação aos conflitos políticos, sindicais, estudantis, no curso dos anos 1950 e 1960, o *terrorismo* nos anos 1970, o *crime organizado das máfias* num período muito longo que conheceria fases de pico entre os anos 1980 e começo de 1990, a *corrupção política*, também este fenômeno de longa duração que explode ju-

dicialmente entre 1992 e 1994, e, por último, o *sentimento de insegurança*, do qual não se pode dizer ainda que tenha se elevado ao nível de uma emergência histórica, mas que vem imprimindo um signo relevante no clima penal do início do novo século.

A resposta penal cada vez suscitada por estas cinco emergências empenhou em fases sucessivas ordenamento e legislação, obtendo o duplo efeito de procrastinar *sine die* as necessárias reformas estruturais do sistema penal e de deixar nele traços relevantes, que desde há muito vêm obstruindo-o e constrangendo-o a fatigantes recuperações, especialmente no que tange ao sistema de garantias a reconhecer aos cidadãos.

9.1 O penal hipertrofiado, a crise das regras, o crescimento da insegurança

Enquanto isso, com o tempo, o sistema normativo penal fez-se hipertrofiado. Ao código e às tantas leis penais especiais produzidas no tempo acrescentou-se uma miríade de normas especiais, aninhadas numa centena de leis administrativas, destinadas a disciplinar as matérias mais disparatadas. Subjugados por uma verdadeira "lei do cúmulo da produção normativa", os Estados operam uma crescente "penalização a rodo", pontilhando de normas penais o "mar de leis" que sai dos seus parlamentos, sem ter depois a estrutura adequada e a força necessária para fazê-las respeitar. E isso é, evidentemente, efeito de uma crise, e motivo de crise ao seu redor.

As origens mais longínquas do fenômeno, junto àquelas mais próximas, estão provavelmente na crise do Estado-Nação e no enfraquecimento do seu poder normativo. O Estado-Nação é o produto histórico de uma fase já superada e se formou sobre pressupostos políticos e ideológicos que estão há tempos às nossas costas. As próprias categorias penais fundamentais, elaboradas entre os séculos XVIII e XIX, na fase de aproximação ao Estado liberal de direito, devem ser submetidas a corajosas críticas de verificação, nessa que já é, ao inverso, uma adiantada fase de *distanciamento* em relação àquele modelo estatal. De resto, a inflação penal, assumida aqui como efeito da crise do Estado-Nação, é também uma de suas causas. Porque o crescimento aberrante da dimensão penal dentro do sistema normativo produz inevitavelmente um severo enfraquecimento da hegemonia da normatividade estatal como um todo, e uma espécie de inelutável deterioração das normatividades penais em particular. Acontece que *sistemas normativos não jurídicos* inteiros, que outrora tinham sua eficácia nas relações sociais, se dissolveram, substituídos por uma demanda de constrição penal, à qual se responde com leis de valor, antes de mais nada, simbólico. A ameaça de pena se reduz frequentemente a mero meio de projeção, para obter um efeito de anúncio, para tranquilizar ou garimpar consenso. Ainda que pareça inacreditável, o enrijecimento das penas ainda é tido como um meio eficaz na representação do penal.

O código penal perdeu a sua centralidade. O Estado Social, legislador por excelência, se vale até demais do penal a título de advertência, quase a assinalar a importância desta ou daquela passagem da sua normatização. Dilatou enormemente o campo das contravenções e inventou o direito penal acessório e o ostentatório. É assim que tantas leis organizativas vêm guarnecidas com obrigações ou proibições equipadas com penas, que deveriam obstar a sua inobservância. Segmentação e pulverização tornam-se regra. Não há mais setor da administração pública que renuncie ao seu pedaço de ameaça penal, para aumentar o seu poder de captura sobre a fração de cidadãos que tem a ver com ela, ou simplesmente para não ser de menos respeito que

as outras. Cada setor, em perfeita autonomia, gera o seu pedacinho de poder punitivo, produz a sua práxis aplicativa, cria as suas linguagens de microssistema, preocupando-se pouco com a utilidade prática de tudo isso. Porque é da experiência comum o fato de que a ameaça de pena fica, de regra, no estado de ameaça, utilizada somente para fazer pressão, para pechinchar pela força, para obter dos cidadãos condutas mais dóceis no confronto com algumas de suas exigências burocráticas.

Nesse quadro, a pena não é mais levada a sério. Ela foi seriamente enfraquecida no seu papel estratégico de prevenção geral, em razão de que os comportamentos ameaçadores vão desde os gravíssimos até os de bagatela, e são tão numerosos e disparatados a ponto de não oferecerem mais nenhum ponto de orientação certo. A inflação punitiva, como era de se prever, corroeu o valor intrínseco do sistema que o superalimentou. Reduzida ao nível de simples sinalizadora do perigo, a ameaça penal perde aquela pouca função dissuasiva que podia restar-lhe e degenera numa prospectiva de mera casualidade. Uma observação, também superficial, das dinâmicas punitivas reais operantes na Itália entre 1900 e 2000 nos diz que a pena atinge "casualmente" um pequeno número daqueles que, por qualquer inclassificável razão, deparam-se com um processo de criminalização secundária. A mesma rápida observação nos faz dizer que esta casualidade é guiada, todavia, por um "instinto" que a conduz invariavelmente a atingir, (ainda que ao acaso) categorias marginais, sujeitos débeis, ou então autores que se deixem particularmente visíveis; deixando fora comportamentos criminosos cobertos ou protegidos, que usam meios discretos ou que podem contar com um *comodum* de origem política, coadjuvado por uma sábia estratégia midiática, capaz de deslocar o *focus* da atenção geral *do problema* (a corrupção, por exemplo, ou fatos de criminalidade econômica) *aos efeitos* que poderiam produzir-se, afrontando-os com o meio do controle legal. E já se insinua, por alto, uma singular e inédita questão, que não parece bem anunciada, em relação à compatibilidade entre a ação judiciária que aplica o ditado da lei e a vontade popular que democraticamente se exprime quando escolhe uma maioria de governo, em ocasião das eleições políticas.

9.2 O "Estado de Segurança"

Estes, e outros a eles relacionados, são os problemas em aberto. O Estado social está visivelmente caminhando na direção de formas que se podem definir com a expressão "Estado de Segurança", nas quais assumem relevante importância *vagues* de opinião que se orientam por perigos imaginados, muito mais do que por fatos demonstrados: dominadas por classes que há tempos praticam um incansável desprezo pelas regras, e, todavia, reclamam inflexível aplicação aos bodes expiatórios do seu sentimento de insegurança.

O que se pode dizer é que, para além das suas contradições, a questão da segurança já está no centro das atenções das políticas penais em muitos países da Europa hoje, e que, pelo seu poder de tão bem se camuflar, não deveria ser nem negligenciada nem supervalorizada. Porque a possibilidade de transformar-se numa emergência de grande porte está toda no grau de cuidado tempestivo (precoce, já não se sabe) ao qual se será capaz de submetê-la. Sabe-se que ela se liga a questões igualmente complexas, como a da imigração, com a existência de um sério descontentamento das periferias e das faixas não integradas do mundo juvenil urbano, com a queda das regras de convivência d'*antan*, das quais se sente falta, depois de, às vezes, ter acelera-

do o seu desaparecimento com estilos de vida inspirados em modelos individualistas e consumistas que se tornaram hegemônicos pelos *mass media*; nasce em grande parte no senso de precariedade e apreensão pelo futuro de grupos que perdem o *status* social ou que temem perdê-lo; é facilitada por algumas dinâmicas da vida urbana tal como o anonimato, a criação de um "mercado de segurança" feito de seguradoras e segurança privada, a humilhação da defesa dos bens da parte de quem os possui, a elevação dos seus valores para quem não os tem e aspira a tê-los; enraíza-se na consciência o fato de que para certas agressões a vítima não tem praticamente defesa, nem dispõe de uma confiável possibilidade de restituição, porque inquéritos policiais e processo penal não parecem instrumentos adequados e, sobretudo, disponíveis.

Um longo trabalho estratégico parece ser a única via realista praticável. Um trabalho que desloque da criminalidade difusa uma parte da atenção historicamente direcionada a ela para outros lugares, afrontando, entre outras coisas, com políticas de controle e legalização, os êxitos criminógenos do proibicionismo em matéria de substâncias estupefacientes e os novos perfis alarmantes do fenômeno prostituição. Um trabalho de longo prazo que reorganize a presença dos tutores da ordem nas cidades, que implante mecanismos de reparação de danos e procedimentos de mediação entre agressor e vítima, que envolva os meios de comunicação num projeto de razoabilidade informativa, dissuadindo-os da atual função de alarme intermitente e do trabalho de má informação que nasce das ênfases, das metáforas bélicas, dos tons paroxísticos com os quais a imprensa em particular tende a apresentar episódios que são nada mais que ordinária criminalidade difusa.

Um trabalho longo, *comme toujours*. A fuga da vingança não é, há séculos, um projeto de pouca monta.

Tradução: Ricardo Sontag

Notas

[1] Publicado originalmente em: FIORAVANTI, Maurizio (a cura di). *Lo Stato Moderno in Europa. Istituzioni e diritto*. Roma e Bari: Laterza, 2004. pp. 163-205. Este escrito expõe de modo sucinto uma experiência nada breve. Pensado para quem se aproxima pela primeira vez a estes estudos, pretende fornecer um quadro feito de tendências e traços da experiência penal moderna e contemporânea: uma síntese, pobre de dados conceituais, que seja orientação e fundamento para aprofundamentos posteriores. O leitor especialista, portanto, deverá ficar desiludido: poucas páginas para muitos séculos de história, questões complexas sumariamente acenadas, linhas gerais no lugar de análises mais precisas, notas escassas e puramente técnicas.

[2] A expressão "il penale", comum em italiano, não existe em português, no qual vem sempre utilizada como adjetivo, sendo a única possibilidade de substantivo "a pena". Porém, a expressão em italiano, como é utilizada por Sbriccoli, refere-se não só ao processo penal ou ao direito penal, por exemplo, mas ao "penal" (substantivo) que pode atravessar questões de processo, de direito penal substancial, questões doutrinárias etc. Portanto, mesmo soando estranho, optei por inventar uma versão substantivada em português para o termo em italiano – "o penal". (N.T.)

[3] O termo hegemônico, neste texto, designa não só o fato de esta concepção de justiça ter se tornado dominante num determinado período, como também um determinado tipo de aparelho judicial fundado, por assim dizer, em metáforas verticalizantes. E, por isso, nesse segundo sentido, o termo hegemônico aparecerá, algumas vezes, substantivado em função do mesmo problema com o termo "penal" (c.f nota 5). (N.T.)

[4] Entre os primeiros, Alberto da Gandini, autor de um *Tractatus de maleficiis* (composto entre 1286 e 1300), e Bonifacio Antelmi, que escreve em torno de 1301 o seu *Tractatus super maleficiis*, seguido do ignoto autor que, aproximadamente na metade do séc. XIV, compõe a *Practica iudiciaria in criminalibus*, impressa no séc. XVI com o nome de Jacopo da Belviso. Os dois primeiros tratados seriam reimpressos mais vezes no séc. XVI, junto ao *De maleficiis* de Angelo Gambiglioni, mais tardio (escrito em Bolonha entre 1438 e 1444), mas inspirado nas mesmas linhas metodológicas: centralidade do processo e do juiz, direito penal medido sob o quadro judiciário, tipos penais construídos em torno do modo de prová-las, categorias penais (imputabilidade, responsabilidade penal, nexo da causalidade, culpabilidade, circunstâncias, tentativa, concurso etc.) elaboradas à partir da dosimetria das penas.

[5] Este nó decisivo na história do penal é analisado mais longamente e de perto no meu *"Vidi communiter observari". L'emersione di un ordine pubblico nelle città italiane del secolo XIII"* In: Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, 1998, pp. 231-268.

[6] c.f. nota 3

[7] Não sem significado, o último artigo da *Leopoldina*, o 119, prescreve que "la pena voluta dalla legge, e decretata dai giudici, sará irremissibilmente eseguita", acrescentando logo depois: "Revochiamo perciò ogni facoltà [...] di accordare diminuzione, permutta, composizione, o condonazione di pene tanto pecuniarie, che afflittive".

[8] O seu período de maior florescimento se deu no século XVI, concomitantemente com o processo hegemônico, com a abertura do ensino do *ius criminale* nas universidades e com a multiplicação das cortes de justiça. Extraordinariamente robusta e rica, sem um sistema, mas densa de conteúdo, a *Practica causarum criminalium* (1526 – 29), conhecida como *Averolda*, de Ippolito Marsili, seguida de inúmeras outras, entre as quais se destacam o *Speculum aureum* (1525) de Roberto Maranta; a *Practica criminalis* (1541) de Jean de Mille; a *Practica criminalis* (1547) de Marco Antônio Bianchi; a *Practica causarum criminalium* (1548) de Ludovico Careri; o *Tractatus criminalis* ou *Practica et theorica causarum criminalium* (1549, revisada em 1568) de Jacopo Novelli; os *Tractatus varii* (1562) de Egídio Bosse; a *Practica criminalis dialogice contexta* (1553) de Pietro Follerio; a *Praxis rerum criminalium* (1554) de Joos Damhouder, tradução e integração de uma prática criminal mais antiga de Philippe Wielant; a *Praxis causarum criminalium* (1566) de Claude Battandier; a famosa e afortunada *Practica criminalis* (1568) de Giulio Claro; a *Theorica et praxis interrogandorum reorum* (1590) de Flaminio Cartari e enfim a monumental *Praxis et theorica criminalis* (1588 – 1614) de Prospero Farinaccio. Para o processo criminal canônico, a *Practica criminalis canonica* (1549) de Juan Bernardo Diaz de Luco e a *Canonica criminalis praxis* (1559) de Pietro Follerio. Para o inquisitorial, o *Iudiciale inquisitorium* (1568) de Umberto Locati, o *Sacro Arsenale* (1621) de Eliseo Masini, o *De officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* (1642) de Cesare Carena e o *Manuale consultorum* (1693, póstumo) de Francesco Bordoni. Um caso particular é o *Tractatus criminalis* (1590) de Tiberio Deciani, que, muitas vezes, se distancia do modelo das *practicae*, para aproximar-se de uma escrita mais sistemática característica de um tratamento autônomo do direito penal: neste sentido precoce e talvez por isso não tenha sido muito afortunado. Tudo isso para o séc. XVI. Muitas *practicae* ainda serão produzidas nos séculos XVII e XVIII, quase todas de tipo compêndio, repetitivas e gregárias.

[9] "Nas causas criminais a ciência pouco ajuda quem não conhece o seu funcionamento efetivo": esta passagem e as citadas acima em: I. Marsili, *Averolda. Practica causarum criminalium*, D. Harsaeus, Lugduni 1551, § *Principium*, nn. 1-4.

[10] 'Convicto' é aquele réu que o juiz – apoiando-se nos resultados do processo e nas coisas que o fez dizer – conduz com os seus próprios argumentos ao ponto que ele não possa negar aquilo que não quer admitir. Segundo F. Cartari, *Theorica et praxis interrogandorum reorum libri quatuor*, Ioannes et Andreas Zenari fratres, Venetiis 1590, lib. III, cap. 1, nº 50.

[11] "Muito útil e indispensável para os juízes dos malefícios, para os advogados, funcionários das

cortes de justiça e todos aqueles que tenham a ver com a justiça, principiantes e especialistas". Fórmula que resume tantas outras, dispersas nos frontispícios de quase todas as *practicae* que tive a oportunidade de ver.

[12] "O juiz deve, pode, se requerido que seja devido; porém, se solicitado que seja possível, não deve, não pode".

[13] G. Claro, *Practica criminalis, totius criminalis iudici ordinem & delictorum poenas complectens* [corrisponde al § *finalis* del *Sententiarum receptarum liber quintus*], Ioannes Gryphius, Venetiis 1568; P. Farinaccio, *Praxis et theoricae criminalis [partes]*, ap. Georgium Variscum & apud Iuntas, Venetiis, 1603-20.

[14] Posso introduzir só de passagem uma anotação que concerne aos princípios penais produzidos interpretativamente na grande fase dos comentadores. Na doutrina cinquecentesca das *practicae*, as opiniões límpidas, atentas, às vezes surpreendemente penetrantes daqueles juristas são evocadas frequentemente como eminentes ou *communes*. Bartolo da Sassoferato, Bartolomeo da Sliceto e Paolo di Castro são recorrentes nos aparatos dos práticos.

[15] O primeiro que parece encaminhar-se nessa direção é Tiberio Deciani (1509-82), autor de um *Tractatus criminalis* escrito no início dos anos setenta do séc. XVI e publicado postumamente em Veneza (apud Ioannem & Andream Zenarios) nel 1590.

[16] Obedecer às leis e aos comandos dos superiores.

[17] A *criminalização primária* é aquela operada pelas leis com a ameaça de uma pena a determinado comportamento. É o procedimento através do qual se estabelece que uma certa ação, em certas condições, constitui crime. A *criminalização secundária* é aquela que se faz com a concreta submissão do (suposto) autor de um crime ao aparato da justiça: polícia, juízes, sentença, prisão. É o procedimento com o qual quem cometeu certos comportamentos pode ser chamado delinquente.

[18] A origem romano-canônica do processo inquisitório público é tida por pacífica, ainda que seria tempo de reconsiderá-la, olhando-a mais de perto.

[19] Um único exemplo entre tantos possíveis. As cláusulas que trazem o procedimento na fase instrutória, *summarie, de plano, sine strepitu (advocatorum) et figura iudicii*, produzidas originariamente no âmbito eclesiástico (*Licet ex omnibus*, Urbano IV, 1261), foram adotadas pela legislação imperial (*Ad reprimendum*, Henrique VII, 1313), recolocadas no processo inquisitório canônico depois de um procedimento interpretativo autêntico (*Saepe contigit*, Clemente V, 1314), empregado, em seguida, frequentemente, no *iudicium publicum* ordinário, também corriqueiramente praticado no processo da Inquisição.

[20] É regra que, tratando-se de heresia, na *copia processus informativi* a ser entregue ao acusado não se revelam os nomes das testemunhas de acusação, ao contrário do que se fez comumente nos *ristretti* dos processos penais ordinários.

[21] A arte de descobrir e sopesar os indícios.

[22] A brevidade do espaço me obriga a esboçar numa síntese extrema esta fase decisiva da história do penal, no curso do qual o sistema em que hoje vivemos vem ideologicamente fundado. Quem quiser aprofundá-la tem à disposição uma literatura interminável, mas eu lhes indico antes de tudo os capítulos VIII e IX de G. Tarello. *Storia della Cultura Giuridica Moderna. Assolutismo e codificazione del diritto* (1976), Il Mulino, Bologna, 1999.

[23] Ficaram às margens quase todos os penalistas 'juristas'. Aqueles que intervieram nas discussões, o fizeram para defender o antigo e o presente, contra o novo que vinha dos ideólogos *philosophes*.

[24] Pessoas acusadas de difundir as pestes no contexto da Europa tardo-medieval. (N.T.)

[25] Os bens protegidos estão num elenco que inclui Estado e administração pública, religião, liberdade, justiça e fé pública, pessoa, propriedade, costumes, honra, tranquilidade pública.

26 O nome "escola clássica" fora uma invenção depreciativa de Enrico Ferri, principal expo-

ente da corrente positivista, que foi afortunada entre os contemporâneos. Posteriormente, o binômio escola clássica – escola positiva circulou sorrateiramente graças à indiferença dos penalistas, que o acharam cômodo, e à preguiça dos historiadores, que ao invés de tratar de controlá-lo o tomaram por bom.

FLORILÉGIO

Leitores d'O Globo

Não sou absolutamente a favor de tal atitude da polícia, no entanto, os jornalistas fazem com que estes bandidos se tornem vítimas. Sofro até hoje as consequências de um assalto na família há seis anos. Consequências irreversíveis. E no entanto, segundo o jornal, esses cidadãos merecem todo o respeito e atenção. Direitos Humanos para eles todos, para as pessoas de bem, nenhum.

Maria Letícia Elfrain (por e-mail, 12/05), Rio.

Pelo que pude ler até agora, percebe-se que o povo apoia Beltrame e Cabral, em relação ao que é feito em termos de segurança pública. Eu também! Hoje caíram nove em duas favelas. Beleza! Há muito que não se lê boas notícias como esta. Não se deixem levar pela rebelião dos coronéis. Eles são plenamente substituíveis. Entretanto, a recíproca não é verdadeira no que tange a governo com raça para encarar a vagabundagem que insiste em denegrir nosso Rio de Janeiro.

Paulo André P. Marques (por e-mail, 30/1/08).

O Globo, Carta dos Leitores, 13.mai.06, p. 6.

O Haiti é aqui

Tão importante quanto a estratégia de permanência nos locais ocupados foi o sistema de ocupação progressiva, lembra Rubem César, que faz um trabalho de recuperação urbanística e social na região de Bel-Air: "A estratégia lá primeiro foi de fazer um caminho, atacando por partes. Depois que domina uma região, fica e move-se para o segundo ponto que foi Cité Militaire. Isso levou um ano, um ano e meio. Só no terceiro ano foram encarar Cité Soleil. A estratégia é criar pontos fortes, como se fossem bases internas ofensivas." (...) Ele compara a atuação de nosso Exército lá, onde houve um trabalho de três anos para se conseguir dominar a maior favela, com a situação recente no Rio: "Aqui nós estamos há um mês em Vila Cruzeiro, e já está todo mundo de língua de fora, ninguém aguenta mais, nem o bandido nem o mocinho nem a sociedade".

O Globo, coluna Merval Pereira, 9.jul.07, p. 4.